

Área: Tecnología

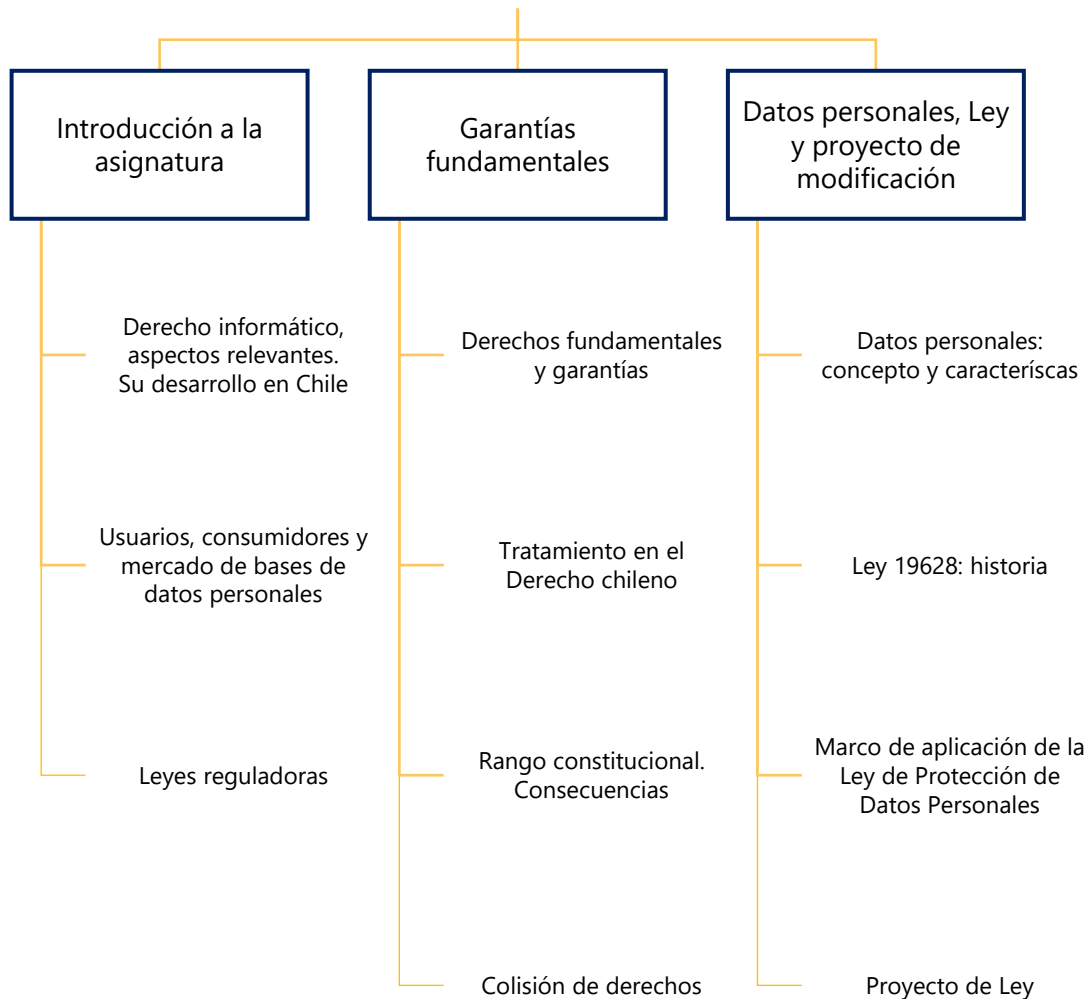
Derecho informático

M1 Vida Privada y protección de bases y datos personales



Mapa de Contenido

Vida Privada y protección de bases y datos personales



Índice

Introducción.....	4
1. Introducción a la asignatura.....	5
1.1 Derecho informático: aspectos relevantes. Su desarrollo en Chile.....	6
1.2 Usuarios, consumidores, mercado de base de datos personales	7
1.3 Leyes reguladoras de la protección de datos personales.....	8
2. Garantías fundamentales.....	9
2.1 Derechos fundamentales y garantías	9
2.2 Tratamiento en el derecho chileno	10
2.3 Rango constitucional: consecuencias	11
2.4 Colisión de derechos	12
3. Datos personales, ley y proyecto de modificación.....	13
3.1 Datos personales: concepto y características	13
3.2 Ley 19.628. Historia	14
3.3 Marco de aplicación de la ley de protección de datos personales.....	15
a. Definiciones.....	15
b. Cómo se tratan los datos personales	16
c. Habeas data.....	17
3.4 Proyecto de modificación a la Ley de protección de datos personales.....	17
Cierre	18
Referencias bibliográficas.....	19

Resultado de aprendizaje

Analiza la normativa vigente en materia de Derecho Informático, señalando Derechos fundamentales y políticas de protección de los datos personales y de seguridad a nivel organizacional.

Introducción

Más de una vez te ha inquietado ese correo desconocido en tu bandeja de entrada, el llamado de una tienda de *retail* a tu teléfono personal, saber si tu empleador revisa tu tráfico en el correo electrónico institucional, si puede colocar término a tu contrato por “mal uso” del mismo; o el rechazo infundado de una institución de crédito para concederte un crédito al calificar el riesgo asociado. Todos estos hechos que tu diario vivir normaliza, alteran derechos naturales y, por tanto, anteriores al derecho de quienes los vulneran. Pero ¿te has preguntado qué derecho prevalece, si el de aquel que quiere capturar tu atención en la compra, o el del empleador que protege los bienes personales de la empresa, su *know how*, su derecho a reclamar lo estipulado en el contrato y en el reglamento interno de ordena higiene y seguridad? ¿Triunfa, acaso, en esta reyerta de derechos, aquel del banco que sabe que 10 años atrás fuiste un contratante incumplidor en una institución de la competencia y que por tanto es riesgoso para su patrimonio concederte ese crédito que tanto necesitas? En suma, tu derecho a la privacidad es de menor o mayor escala que todos estos; y siendo así, ¿cuál es su alcance?

Nuestro ordenamiento jurídico, ¿nos proporciona herramientas para una adecuada defensa? Y, por otra parte, ¿debemos defendernos?, ¿de quién depende esa decisión?, ¿hay organismos del poder administrativo encargados de fiscalizar el almacenamiento y tráfico de nuestros datos personales?; y en definitiva, ¿somos dueños de nuestros datos personales y cuál es el alcance de nuestra privacidad? Todas estas preguntas y muchas otras se contestan día a día en nuestros Tribunales de Justicia.

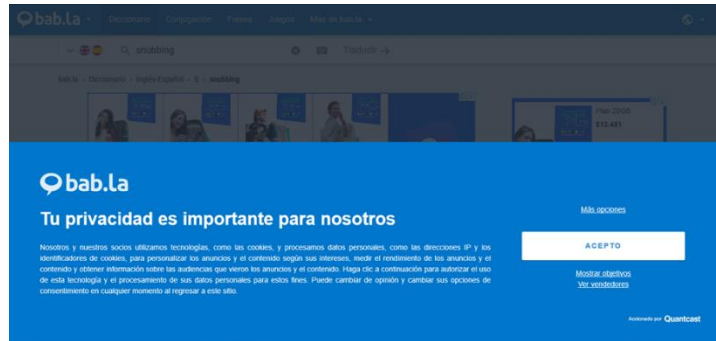
Nuestro ordenamiento jurídico recién crece para regular, proteger y sancionar. Pero bueno, ya conocemos la labor de la justicia; y la pregunta que nace, ¿cuál es tu rol en este juego de derechos?, ¿tienes alguno?, ¿te corresponde contribuir desde tu formación y conocimientos técnicos a dar primacía a una de estas posiciones y derechos, casi siempre, tan antagónicos? Pues bien, la respuesta que ya te avanzamos, es que sí lo tienes y uno muy importante, pues si bien, es el derecho quien regula los aspectos técnicos, son los técnicos y profesionales como tú los llamados a cooperar en las decisiones operacionales y estratégicas de la empresa, razón por la que tu formación necesita un conocimiento que pueda contribuir a que esa toma de decisiones sea no solo criteriosa, sino la correctamente ajustada a derecho en el procesos de formación de políticas, de buenas prácticas y de un gobierno TI, que tributando al gobierno corporativo, no abandone su mirada al ordenamiento jurídico en su conjunto.

Vamos, anímate y comencemos.

1. Introducción a la asignatura

A medida que el concepto de libertad se desarrolla y complementa, ha encontrado en ciertos "derechos apéndices" una forma de crecimiento, sustento y protección. Entre ellos, el **derecho a la intimidad**, a la **privacidad**, el **derecho a la soledad** y el **derecho a la identidad**, han comenzado a tener un desarrollo particular, pasando de tener una mera complicidad con la libertad a desarrollarse

en particular. Esta afortunada simbiosis ha particularizado estos derechos entregando regulación y tutela para los mismos, separados del derecho a libertad personal. Se pueden ver en los siguientes ejemplos:



1. Tratados internacionales:

Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre del año 1948, que señala que el derecho a la vida privada es un derecho humano);

2. Constituciones de diversos países:

Artículo 18 N° 1 de la CPE: "La Constitución Española N°1 Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen...N° 3: Se garantiza el secreto de las telecomunicaciones y en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas; y N° 4.- La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos y hoy en día la CPE de Chile que señala en su artículo 19 N° 4 "La Constitución asegura a todas las personas, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley"; entre otras)

3. Leyes de toda clase, civiles, penales, laborales y administrativas.

En particular, el derecho a la protección de datos ha tenido un enorme desarrollo en el ámbito interno como en el extranjero, reconociendo formar parte de la identidad personal, incluso aspectos de tipo tecnológico, pero siempre entendiendo, salva escasas y criticadas excepciones, que los datos personales que la ley protege son exclusivamente aquellos que corresponden a las personas naturales y no a las personas jurídicas o mercantiles.

Ejemplo de esto es lo que ocurre con el **concepto de IP**. Efectivamente la tendencia moderna de identificar la IP con el dominio y como dato personal del titular, ha tenido creciente desarrollo en Europa. Es así como, según el criterio de (AEPD) Agencia Española de Protección de Datos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la IP, no es sino un dato personal más. En Chile, la actual aparición de sentencias de nuestra Corte Suprema de Justicia (roles 27.889-2017 y 37.301-2017, todas ellas muy discutidas y con sendos votos de disidencia en la discusión del fallo) que plantean la posibilidad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales a las personas jurídicas; no obstante, el tenor claro de la Ley 19.628.

En fin, **el dato personal avanza a no ser un derecho en sí mismo**, sino a convertirse en un **calificador**, en un **rótulo**, con el que **se pretende categorizar denominaciones, situaciones, creencias, instrumentos tecnológicos** y en general **cualquier aspecto de la vida de las personas que los identifiquen de manera material, jurídica e incluso digital**.

La vinculación de este derecho con la tecnología informática y las comunicaciones ha sido caldo de cultivo para modificaciones legales de importancia en el mundo, y Chile no es la excepción. La **ley 19.628** sobre Protección de Datos Personales que fue conocida en sus inicios como La Ley Dicom, enfrenta una importante modificación que pretende dar mayor protección a nuestros datos, crear un organismo especializado que fiscalice y sancione el tratamiento de datos personales y a los encargados del almacenamiento de datos personales, aplicando altas sanciones en caso de incumplimiento. Así es como políticas informáticas, el manejo de las vulnerabilidades de los sistemas de tratamiento de información, la formación del *firewall-man*, son urgentemente requeridas, para atender el crecimiento vertiginoso de demandas ciudadanas en busca de protección de su derecho a la identidad personal.

1.1 Derecho informático: aspectos relevantes. Su desarrollo en Chile.

Debemos entender el Derecho como un conjunto de normas jurídicas, principios, reglas de conducta, que regulan la vida de las personas en sociedad; y que, normalmente determina sanciones para el caso de su incumplimiento.

La aspiración del derecho es omnicomprensiva, pues pretende estar en la regulación de todos los actos y omisiones de las personas que puedan traer una consecuencia jurídica para otros. Para cumplir este fin, ha debido definir previamente qué es lo que pretende proteger, y de tal forma, si protege y garantiza derechos fundamentales frente al Estado y las personas, creando y regulando instituciones políticas, estaremos en presencia del Derecho Constitucional. Si su aspiración es la protección de la vida y la integridad física de las personas, el honor, la propiedad privada o pública, etc., estaremos en presencia del Derecho Penal, en desde cierto punto de vista del Derecho Civil; y si lo que se pretende regular es la relación existente entre empleadores y trabajadores, no cabe duda alguna que estaremos hablando del Derecho Laboral.

El **derecho informático**, por su parte, no es especial pues **su afectación es transversal**. Por tanto, toca al derecho constitucional, al civil, al laboral y al comercial, adaptándose a las normas y principios de cada uno de ellos. El motivo es uno: **la tecnología informática es desde hace mucho un aspecto más de nuestro vivir**. A través de los medios tecnológicos recibimos y almacenamos información, pero también dominio, entregamos emociones, pero a su vez



realizamos operaciones monetarias. **La tecnología informática no solo es un medio sino nuestra identidad**, la manera como, “lo que somos” y “lo que tenemos”, se manifiesta a través de bits y códigos binarios.

Teniendo una regulación antigua en el mundo, España, Croacia, Alemania, Inglaterra, entre otros, en Chile hace su aparición en el año 1993, por medio de la Ley 19.223, que intentó (sin mucho éxito) regular los delitos informáticos que comenzaban a aparecer producto de la adaptación de nuestra tecnología al entorno global. La ciber comunidad internacional nos incluyó en la afectación del ciber espionaje, del sabotaje y del fraude informáticos y aprendimos con rapidez. Hoy esa ley está pronta a ser derogada, toda vez que, en el año 2017, Chile aceptó la invitación que le formuló El Consejo de Europa para formar parte del Convenio de Budapest, que tiende a estandarizar los delitos informáticos, forma de investigación de estos y sanciones aplicadas para todos los países miembros, no solo de Europa, sino de Japón y algunos países americanos.

En el año 1998 se dicta la **Ley sobre Protección de Datos Personales N° 19.628**, sin mayor aspiración que regular la información comercial, por lo que fue conocida como la Ley Dicom; sin embargo, **en el año 2012 es modificada por la ley 20.575**.

1.2 Usuarios, consumidores, mercado de base de datos personales

¿Quién es el dueño de los datos personales? Pues bien, claramente el propietario es la persona, natural o jurídica, pese a que la ley chilena 19.628, sobre protección de datos personales solo los regula respecto de la persona natural (artículo 2 letra ñ ley 19.628); y su derecho arranca según hemos dicho del carácter fundamental del mismo, y no del derecho de propiedad que sobre otros derechos garantiza la CPE en el artículo 19 N°24 de la misma.



En el ejercicio de este derecho, **el consumidor no está obligado a entregar información a los proveedores**, respecto de aspectos que digan relación con su identidad material o digital; y si la entregan, saber en qué se va a utilizar esa información. El usuario, por su parte, tiene derecho a que no se envíen registros de morosidades por el no pago de los servicios de básicos del inmueble que ocupa.

Los responsables de los registros de datos están habilitados para solicitar hacer pública la morosidad solo si ella consta en un pagaré, cheque protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; o letra de cambio, salvo que las deudas se hayan originado en el período de cesantía del deudor (artículo 17 le 19.628).

El tratamiento de los datos personales requiere del consentimiento del titular de estos. Dicho consentimiento no implica en sí mismo una renuncia del derecho: **el titular siempre seguirá siendo dueño de este**, razón por la que conserva el derecho de revocación del consentimiento otorgado, así como la prohibición implícita de ceder esos derechos a un tercero.



1.3 Leyes reguladoras de la protección de datos personales

"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias", sostiene la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En Chile, como en las legislaciones modernas, **el mandato de protección de los derechos personales está concedido por la Constitución a la Ley.** Esta última es la **Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) N° 19.628**, de 28 de agosto de 1999. El Título Primero trata de la utilización de los datos personales, el Segundo, de los derechos de los titulares de los datos; el Tercero, de la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial; el Cuarto, del tratamiento de datos por organismos públicos; Quinto, de la responsabilidad por las infracciones a esta ley.

Esta ley **fue ampliamente modificada por la ley 20.575**, que se encarga de definir y regular el llamado **principio de finalidad en el tratamiento de los datos personales** respecto del tratamiento de datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial, los que solo deberán ser utilizados en la evaluación del riesgo comercial y para el proceso de crédito. Por tanto:

"Con todo, los prestadores de salud no podrán consultar sistemas de información comercial de ningún tipo, ni aun con el consentimiento del paciente, para efectos de condicionar o restringir una atención de urgencia." (artículo 141 Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N° 1 de 2006, del Ministerio de Salud).

La Ley pretende blindar al titular de los datos en su derecho a la privacidad, intimidad, honor e identidad. Sin embargo, siendo su fuente legal tan antigua (se basa fundamentalmente en la ley orgánica N°1 del 5 de mayo de 1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, de España; la ley N°78-17, de 6 de enero de 1978, sobre informática, ficheros y libertades, de Francia; la ley de 12 de julio de 1984, sobre protección de datos, de Gran Bretaña; la ley N°48, de 9 de junio de 1978, sobre registros de datos personales, de Noruega; el artículo 1071 bis del Código Civil argentino; y el artículo 9 del Código Civil francés, entre otros. Consta de cinco títulos y 26 artículos permanentes), no tiene la capacidad de comprender hoy en día, su nuevo concepto, nuevas vulnerabilidades y actuales formas de comercio; razón por la que se ya se ajusta en segundo trámite constitucional un proyecto que modifica de manera muy amplia la misma entregando nuevas responsabilidades a los encargados de los



banco de datos y de quienes forman parte de estos, creando un organismo regulados y sancionatorio, siguiendo el símil español del año 2018.

2. Garantías fundamentales

2.1 Derechos fundamentales y garantías

Todo derecho necesita indemnidad en su goce y ejercicio, razón por la que la plataforma que le sirva de medio de expresión tendrá particular relevancia a la hora de la toma de decisiones en el control de su exposición y desarrollo.

El desarrollo de la TIC no obsta a la indemnidad de los derechos amenazados por la tecnología. Las nuevas tecnologías son cada vez más vulnerables a la vigilancia remota y a la interceptación electrónica, razón que, sin duda afecta, no solo afecta a estos sino también los derechos asociados al dominio.



Pues bien, aun cuando la vulnerabilidad de los medios traiga consigo la mera perturbación del derecho y no su privación, nosotros -los titulares de estos- queremos que nuestros derechos se mantengas prístinos y dentro de nuestra esfera de seguridad, más aún si se trata de derechos humanos, cuya categorización trae aparejada mecanismos de defensa superiores a los derechos no garantidos por la Constitución Política.

El Derecho a la Privacidad se reduce a la forma en que el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula: "nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación" y que "toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques"; o como se describe en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 12, el cual establece que "nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques".

El **derecho chileno garantiza este derecho fundamental en los números 4 y 5 del artículo 19 de la CPE**, en el cual señala que La Constitución asegura a todas personas "el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales", "el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley", y "la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas

determinados por la ley”, respectivamente. Haciendo presente que la garantía de protección de datos personales se debe a la reforma reciente del texto constitucional (Ley 20.050 de 16 de junio de 2018).

2.2 Tratamiento en el derecho chileno

La privacidad, como derecho fundamental de reconocimiento constitucional, delega en la ley su forma, condiciones, tratamiento y protección (más allá de la protección que recibe en su calidad de derecho garantido en la CPE por el recurso de protección-art 20 de la CPE).

La naturaleza de la ley reguladora dependerá el estadio en que el derecho se manifieste o afecte; y así la ley podrá ser de naturaleza civil y por tanto de características relacionales (derecho-obligación) y eventualmente compensatorias por medio de la acción de indemnización de perjuicios. Podrá ser de naturaleza penal si protegiendo la privacidad mediante condenas de privación de libertad y otras anexas; o bien laboral en la relación trabajador empleador en el ámbito de las materias propias de la relación laboral.



En materia civil, se manifiesta y regula a través de la ley 19.628 sobre Protección de datos Personales, y su protección es deficitaria. Entre las principales falencias, Pablo Viollier (“El Estado de la Protección de Datos en Chile”) describe: “la ausencia de sanciones efectivas, la falta de regulación del flujo transfronterizo de datos personales, la autorización del uso de datos para marketing directo sin consentimiento del titular, la falta de registro de bancos de datos privados, la ausencia de una autoridad pública de control, excepciones amplias al consentimiento para el tratamiento de datos, y la falta de mecanismos procedimentales de resguardo efectivo”. Solo en el artículo 16, desarrolla el llamado habeas data, una acción común en las legislaciones sobre protección de datos. Con ella el titular regula el tratamiento de sus datos personales recurre al Juez de letras del domicilio del encargado del banco de datos, cuando solicitando la modificación, información, exclusión o bloqueo de sus datos personales, el responsable del almacenamiento y publicación de los datos no responde dentro del plazo de 2 días hábiles o la negare por una causa distinta de la seguridad de la nación o el interés nacional.

El Código Penal, en su párrafo V, protege La vida privada de las personas, en los “delitos contra el respeto y la protección de la vida privada y pública de la persona y su familia”, artículos 161-A y B. La Ley sobre delitos informáticos 19.223, que tipifica los delitos de sabotaje, fraude y espionaje informático.

En el derecho laboral, el Código del Trabajo en su artículo 5to, consagra la protección al derecho a la privacidad del trabajador señalando “El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos”. Derecho que cautela mediante el llamado procedimiento de tutela laboral de los artículos 485 y siguientes del mismo código.

2.3 Rango constitucional: consecuencias

El derecho a la privacidad, tal cual se ha dicho es asegurado a todas personas por la Constitución Política en los artículos 4 y 5 del texto constitucional (N° 4: "El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley"; y N° 5: "La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley").



Lo más importante del reconocimiento de estos derechos fundamentales en la Constitución es que **cualquier norma jurídica de rango inferior a la Constitución que trate estos derechos y que los desconozca o altere de cualquier forma que implique un desconocimiento de los mismos, primará siempre, en todo caso la norma constitucional**, razón por la que dicha norma puede ser dejada sin efecto (para el caso particular) por un recurso que se denomina **inaplicabilidad por inconstitucionalidad** que se deduce en el Tribunal Constitucional, si lo discutido es una ley. Por otra parte, la falta de norma jurídica "legal" no es un obstáculo para la aplicación de la norma constitucional. Este **carácter supletorio** implica que **el derecho existe por el solo hecho de estar garantizado en la Constitución**, no porque él no esté contenido en una norma jurídica de rango menor.

Ejemplo

Un ejemplo de esto lo encontramos en la discutida **ley de tramitación electrónica del Poder Judicial**, que incluye datos sensibles de familia, penales, civiles, laborales, del comercio, etc, razón que nos puede llevar a conocer la situación particular de cualquier sujeto involucrado en un juicio con todas sus particularidades. Pues bien, dicha ley tiene una norma que dice: «Se prohíbe el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial sin su autorización previa. La infracción cometida por entes públicos y privados a lo dispuesto en este inciso será sancionada conforme a la Ley 19.628» y el punto es ¿qué pasa con el titular del dato? En esta situación se da la extraña situación en que (no sabemos a qué título) el Poder Judicial se transforma en encargado del banco de datos y a la vez en dueño de nuestros datos, los que no hemos cedido ni voluntaria ni forzosamente.

Entonces, ¿dónde queda la norma constitucional e incluso la propia ley de protección de datos?, ¿qué prima acá, la ley de tramitación electrónica del Poder Judicial o la Constitución? Pues bien, claramente la respuesta ya la hemos dado. Sin embargo, el asunto, pese a tener solución doctrinaria no para lo mismo con la modificación que debe hacerse a esta ley.

Por otra parte, dicha consagración sostiene la acción de tutela sobre derechos fundamentales del trabajador en contra del empleador que afecta su derecho a la privacidad (por ejemplo, revisando su correo electrónico).

Siguiendo esta última línea y buscando un análisis en lo práctico, lo relevante del reconocimiento constitucional se encuentra en la existencia del denominado **recurso de protección**, que es de fácil acceso, no requiere patrocinio de un abogado y en que su presentación no requiere de ningún formalismo. Se interpone en la Corte de Apelaciones del lugar de ocurrencia del acto u omisión ilegal o arbitrario, dentro de 30 días corridos siguientes. Su tramitación la realiza la propia Corte de Apelaciones, casi sin intervención del recurrente, razón que lo transforma en un mecanismo de muy sencillo uso.

Esto último lo podemos reflejar, por ejemplo, si en una empresa se confecciona y sociabiliza una política TI consistente en que se va a aplicar en ciertos terminales de la empresa, secretaría, contabilidad, ventas, etc. un programa, por medio del cual, el empleador podrá acceder de manera remota a ellos, a fin de verificar la correcta ejecución de las labores ordenadas y corregir, si fuera necesario los errores que se cometieran en su desarrollo.

Pues bien, en este caso, cualquiera de los trabajadores afectados con esta medida, podrían señalar, "con todo derecho", la afectación no solo de un derecho constitucional por medio del recurso antes dicho, sino también una acción de tutela laboral por vulneración de un derecho fundamental, cual es el de la privacidad. (cuestión que tuvo que conocer La Dirección del Trabajo, pronunciándose de la forma como lo analizaremos, más en desarrollo. en el módulo 3).

2.4 Colisión de derechos

En toda relación obligacional, encontramos, a lo menos, **dos partes** y por tanto **dos derechos en pugna**. La **intención** de cada parte en la relación jurídica es **obligarse menos y obtener a cambio el mayor beneficio**, sin necesidad de que sus derechos sean limitados, ni mucho menos amenazados, perturbados o derechamente privados de su esfera de control.

En este ámbito, el encargado del banco de datos que recibe parte de la identidad del sujeto material, cree tener un derecho sobre el control de los datos que recibe, mientras el titular de los derechos alega el carácter de fundamental de los mismos, de acciones constitucionales para protegerlos y del habeas data ya mencionado. En el mismo caso está el empleador, cuyas facultades son expresamente reconocidas en el artículo 5to del Código del Trabajo, pero estableciendo desde ya el límite el "respeto de las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieren afectar la intimidad, vida privada y la honra de estos."



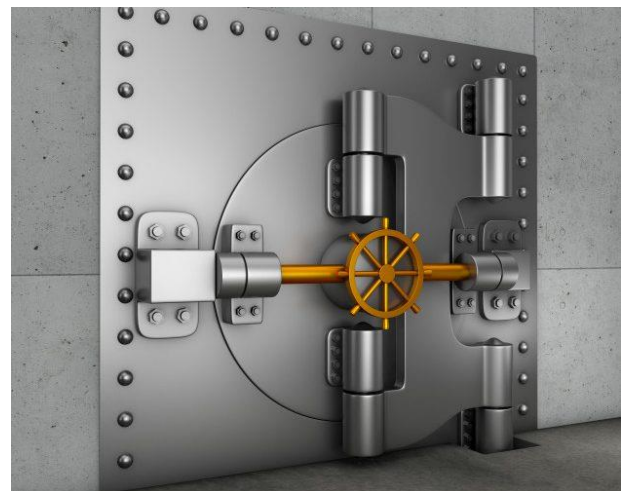
En cuanto a qué derecho resulta primar sobre el otro, no cabe dudas que la primacía de los derechos fundamentales está muy por sobre del mero derecho de propiedad que el empleador tiene sobre sus medios de producción, o que el encargado del correspondiente banco de datos tiene sobre el mismo. Solución que no solo es doctrinaria, sino que tiene fundamento legal, como se ha dicho en los artículo 16 de la Ley 19.628, 5to del Código del Trabajo, 19 N°4 y 5 de la Constitución Política del Estado.

No obstante, la discusión ha llegado a los Tribunales y un reciente fallo (a propósito de la acción de tutela perdida por un trabajador, a quien habían despedido por haber encontrado en su correo electrónico institucional señales claras de haber realizado trabajos profesionales para la competencia, mientras mantenía contrato vigente con su actual empleador) de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, que analizaremos en el módulo 3 de este curso.

3. Datos personales, ley y proyecto de modificación

3.1 Datos personales: concepto y características

Dato personal o dato de carácter personal es uno relativo a **cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables** (ley 19.628 artículo 2 letra f). Agrupa los siguientes elementos: nombre, edad, miembros del grupo familiar, enfermedades del titular y de los miembros de su familia, actividades deportivas riesgosas que desarrolla el titular, tendencia sexual, religión, política, pasatiempos, profesión, ingresos, fuente de estos, bienes inmuebles a su nombre, propiedad en vehículos, acciones, depósitos a plazo, situación tributaria, seguros de vida, siniestros ocurridos, deudas y períodos de estas, actividades voluntarias riesgosas (ejemplo, ser bombero). Del mismo modo, la identidad digital, nombre de usuario, hasta la IP.



Efectivamente, la Agencia Española de Protección de Datos, organismo fiscalizador y controlador del tratamiento de datos personales en España, es del criterio de tratar la IP como dato personal, toda vez que "se puede obtener información adicional de los usuarios a través de la IP por medios razonables, por ejemplo a través de los proveedores de acceso a Internet (Telefónica, Vodafone, etc.), administradores de redes locales, o "utilizando medios invisibles de tratamiento para recoger información adicional sobre el usuario, tales como cookies con un identificador único o sistemas modernos de minería de datos unidos a bases de datos con información sobre usuarios de Internet que permite su identificación". En el mismo sentido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien también realizó la misma asimilación. Estas referencias son muy pertinentes al derecho chileno, siempre que la ley de protección de datos se encuentra en actual modificación y la tendencia nacional es replicar lo ocurrido en Europa (y sobre todo en España) respecto de los avances del Derecho Informático y en especial, la forma en que se regula el tratamiento de datos y delitos que ocupen para su comisión de medios tecnológicos informáticos.

En cuanto a la **aplicación del dato personal**, la definición legal es clara en cuanto a definir los datos personales en relación con las personas naturales o materiales, cuestión que se complementa con lo que dispone la letra ñ del mismo artículo 2, al definir el titular de los datos personales señalando “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia Chilena, en (hasta ahora) 2 fallos, ha resuelto extender la aplicación de la ley de protección de datos a las personas jurídicas (roles 27.889-2017 y 37.301-2017). Dicha extensión legal ha sido duramente criticada por no haberse ajustado al tenor preciso de la ley. No obstante, los fallos existen y para estos fines es necesario hacerlos presente.

3.2 Ley 19.628. Historia

La ley 19.628 sobre Protección de Datos Personales, fue publicada en con fecha 28 de agosto de 1999 y su origen se debe a iniciativa parlamentaria en el año 1993 (en ese mismo año entraba en vigencia en Chile la Ley 19.223 sobre delitos informáticos) presentada al Senado de la República. Modificada por ley 20.575 de 17 de febrero de 2012 y de alguna forma complementada en su aspecto público por la Ley 19.628, denominada también Ley de Transparencia.

Si bien el derecho sobre la privacidad e intimidad son de antigua regulación (anteriores a la informática y por cierto a la idea de la existencia de una red de ordenadores que comunicara a distintos usuarios de computadores), la llegada de internet y la tecnología de la información y de las comunicaciones pasó a convertirse en un medio más no solo almacenamiento de información personal, sino de tratamiento de la misma y, por tanto, peligroso para el ejercicio y goce de ciertos derechos fundamentales, como la privacidad, la intimidad, la identidad y el honor. Ya la Constitución Española de 1978 (según hemos dicho) trataba estos conceptos y en las instituciones internacionales (más aún en las europeas) la protección del dato personal y su tratamiento no sólo eran tema, sino ley.

Chile, atendido el concierto internacional y la recién publicación de la ley sobre delitos informáticos, comenzó a trabajar en la Ley 19.628 (la que una vez publicada, pronto modificaría) para tener como resultado una ley que soluciona muy parcialmente el fin para el que fue creado. Efectivamente, esta no es una buena ley y el motivo es el siguiente:

“no describe con exactitud el objeto regulado por la ley, la carencia de un registro de bases de datos en manos de particulares, la falta de un órgano administrativo fiscalizador, la inexistencia de un procedimiento de reclamo idóneo, la ausencia de un catálogo de infracciones y sanciones efectivas, la inexistente regulación para la transferencia internacional de datos, el establecer que la información personal es pública por regla general, el no abordar el tema de las personas jurídicas, el no exigir la aplicación de medidas de seguridad, la falta de autorización de los titulares de datos por un sistema que establece gran cantidad de excepciones al consentimiento con pocos casos en que pueden oponerse al procesamiento de sus datos, la ausencia de normas precisas para la responsabilidad civil extracontractual adaptadas al caso, la inexistencia de tipos penales específicos asociados a la materia, entre otras”. (Anguita, 2007: 331-342, 563-567; Jijena, 2005: 75-80)



Por dicho motivo, con fecha 15 de mayo de 2017, se ingresa proyecto de Ley al Senado, que modifica la Ley 19.628; sin embargo, aún se encuentra vigente.

3.3 Marco de aplicación de la ley de protección de datos personales

Tal cual lo hemos señalado, la **Ley 19.628**, a través de su articulado, **busca la protección de los datos personales a partir de la regulación de obligaciones de hacer y de no hacer de los encargados de los bancos de datos.**

Parte señalando su marco de aplicación: "El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción del que se efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19, N° 12, de la Constitución Política."

a. Definiciones

Luego, en el **artículo 2°** nos entrega la definición de una serie de **conceptos** que son materia de su regulación, todos ellos relevantes:

- "a) Almacenamiento de datos, la conservación o custodia de datos en un registro o banco de datos.
- b) Bloqueo de datos, la suspensión temporal de cualquier operación de tratamiento de los datos almacenados.
- c) Comunicación o transmisión de datos, dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas.
- d) Dato caduco, el que ha perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia o, si no hubiese norma expresa, por el cambio de los hechos o circunstancias que consigna.
- e) Dato estadístico, el dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable.
- f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.
- g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
- h) Eliminación o cancelación de datos, la destrucción de datos almacenados en registros o bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello.

- i) Fuentes accesibles al público, los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes.
- j) Modificación de datos, todo cambio en el contenido de los datos almacenados en registros o bancos de datos.
- k) Organismos públicos, las autoridades, órganos del Estado y organismos, descritos y regulados por la Constitución Política de la República, y los comprendidos en el inciso segundo del artículo 1º de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- l) Procedimiento de disociación de datos, todo tratamiento de datos personales de manera que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona determinada o determinable.
- m) Registro o banco de datos, el conjunto organizado de datos de carácter personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización, que permita relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de datos.
- n) Responsable del registro o banco de datos, la persona natural o jurídica privada, o el respectivo organismo público, a quien compete las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos de carácter personal.
- ñ) Titular de los datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.
- o) Tratamiento de datos, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma.”

b. Cómo se tratan los datos personales

En esta parte, la **voluntad** del titular del dato personal es la palabra ángulo de la ley. Ninguna corporación privada puede ocupar datos personales sin la voluntad del individuo de quien forman parte

Atención: En esta parte resulta importante hacer presente que **los datos no le pertenecen al sujeto en propiedad, pues los datos son el propio individuo:** todos ellos constituyen su identidad, sea física o digital, de manera que ellos solo pueden ser ocupados por terceros, siempre que el sujeto titular lo autorice.

Solo los datos personales que provienen o se recolectan de fuentes accesibles al público no requieren de la autorización de los titulares, según lo señala la ley (art 4to), pero cuando ellos sean de carácter económico, financiero, bancario, o comercial, o cuando se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento.

Derechos del titular de los datos:

- a.- Derecho de información de los datos relativos a su persona, de donde proviene esa información y el propósito del almacenamiento.
 - b.- Modificación de los datos.
 - c.- Eliminación en aquellos casos que el dato esté caduco o su almacenamiento carezca de fundamento legal.
 - d.- Bloqueo del dato cuando ellos hayan sido entregados voluntariamente o se usen para comunicaciones comerciales y no desee el titular que su dato siga formando parte de las mismas.
- El titular puede solicitar cualesquiera de los 3, cuando a su juicio el dato se encuentre.

c. Habeas data

Que según se ha dicho, es una acción común en las legislaciones sobre protección de datos. Con ella el titular regula el tratamiento de sus datos personales, recurre al Juez de letras del domicilio del encargado del banco de datos, cuando solicitando la modificación, información, exclusión o bloqueo de sus datos personales, el responsable del almacenamiento y publicación de los datos no responde dentro del plazo de 2 días hábiles o la negare por una causa distinta de la seguridad de la nación o el interés nacional.

3.4 Proyecto de modificación a la Ley de protección de datos personales

Este nuevo proyecto afecta la ley en su globalidad. Amplía el concepto de dato persona, señala nuevos derechos al titular de los mismos, señala una nueva regulación de la voluntad del titular del dato al momento de la entrega del mismo, trata acerca de la cesión del dato personal, crea un organismo fiscalizador a cargo del control de las obligaciones de los encargados del banco de datos y de las vulnerabilidades tecnológicas



de los mimos que pudieran representar amenaza de los datos que tratan o almacenan, señala procedimientos para hacer cumplir las obligaciones de los encargados del banco; y crea sanciones importantes a las infracciones que se cometan en el tratamiento y almacenamiento de los datos.

Cierre

El derecho informático, de aparición reciente, navega entre diversas áreas del derecho, sin principios propios ni definidos, mimetizándose con aquellas áreas en las que interviene, siendo su factor común la existencia de la tecnología de la información y las comunicaciones y de como ella afecta las distintos estadios de la vida de las personas, jurídicas o naturales y en ocasión sólo respecto de estas últimas.

De las distintas aristas que el derecho entrega, resulta relevante conocerlas todas, precisando y deteniéndose fundamentalmente en las responsabilidades. Esto por cuanto, al ser el medio informático el área de desarrollo de este derecho y dependiendo la manipulación y conocimiento de la tecnología del profesional o técnico de la información, carecer de información respecto de su regulación es como si un conductor ignorara las normas del tránsito alegando que dicho conocimiento pertenece al área del derecho y a él sólo le corresponde preocuparse del saber técnico automotriz y por tanto, de la combustión, sistema de frenos, filtros, desplazamientos, etc.

La intromisión que la tecnología tiene en la vida diaria nos obliga, no solo a disfrutar de ella sino a cuidarnos de la misma. Su mal uso puede significar la alteración, perturbación o privación de derechos fundamentales como el derecho de privacidad, intimidad, identidad y honor; y la ley debe estar a la altura para regular el derecho, forma de ejercerlo, ante quien, cómo, en qué circunstancias; y como contrapartida fijar límites a quienes son los guardadores de los datos que los reciben en una suerte de depósito, estableciendo sanciones para el caso de mal uso, del aprovechamiento económico de los mismos, del perjuicio que pudieren causar a sus titulares en el evento que los sistemas que los contengan carezcan de una adecuada seguridad informática que permita que los datos contenidos en sus bancos sean alterados, bloqueados y/u obtenidos sin la voluntad del titular de los mismos.

Hoy la ley que regula estas materias no es lo suficientemente inclusiva. Carece de elementos que permitan al titular de los datos gozar de la tranquilidad necesaria que su identidad no transita sin su autorización y que en definitiva no está siendo protegida. Sin embargo, y de manera afortunada, los legisladores se han ocupado y por medio de una modificación de esta, esperan incluir en la nueva ley, elementos suficientes que garanticen la adecuada regulación del derecho al titular de los datos y las obligaciones que debe cumplir su contraparte, el encargado del banco de datos.

Referencias bibliográficas

Código Penal Chileno.

Código del Trabajo de Chile.

Constitución Política del Estado de Chile, actualizada año 2019.

Jara, J., Pincheira, C. y Vera, F. La privacidad en el sistema legal chileno [Ebook] (N° 8), Santiago de Chile: ONG Derechos Digitales. Recuperado de <https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/pp-08.pdf>.

Ley 19.628, sobre protección de datos personales.

Ley 20.575, que Establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.

Revista Chilena de Derecho y Tecnología, volumen 6, número 2, páginas 135 a 152, publicado el 30 de diciembre de 2017.

Rostiñ, I. (2015). Sobre la Ley de Protección de la Vida Privada: La importancia de una "fuente legal" y su aplicación en las Personas Jurídicas. Ius Et Praxis, 21(2). doi: 10.4067/S0718-00122015000200014. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122015000200014

Sanz Salguero, F. (2016). Relación entre la protección de los datos personales y el derecho de acceso a la información pública dentro del marco del derecho comparado. Ius Et Praxis, 22(1). doi: 10.4067/S0718-00122016000100010. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122016000100010.

Sernac (2020). Ojo: Exija el cuidado de sus datos personales - Portal SERNAC. Recuperado el 9 de marzo de 2020, de <https://www.sernac.cl/portal/607/w3-article-3389.html>.

Viollier, Pablo (2017).; El Estado de la protección de datos personales en Chile, Derechos Digitales. <https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/PVB-datos-int.pdf>